

ASHRAF BIN MD. RAZI
lwn
KETUA PENDAKWA SYARIE

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Prof. Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Hj. Mokhtar (Panel), Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Panel), Pada 30 Januari 2018 Bersamaan 13 Jamadil Awwal 1439H]

Kes Mal No : 10000-166-0001-2017
[Rayuan Jenayah-Kesalahan Poligami]

Peguam Perayu:

Mohd Zaidi bin Md. Zain daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguam Responden:

Ketua Pendakwa Syarie Selangor

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu kes rayuan yang telah difailkan oleh Perayu (Asharaf Bin Md. Razi) terhadap keputusan Y. A. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) di Shah Alam yang diputuskan bertarikh **21/4/2016** di dalam kes jenayah Syariah **10500-166-0005-2016**.

FAKTA KES

[2] Pada 23/4/2015, melalui kes Jenayah No. 14003-166-0226-2011 Perayu telah didakwa di Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam di atas kesalahan berpoligami tanpa kebenaran Mahkamah di bawah seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003.

[3] Selepas pertuduhan dibacakan, Perayu mengaku bersalah ke atas pertuduhan tersebut. Atas pengakuan bersalah, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam (Hakim Bicara) telah mensabitkan kesalahan Perayu bagi pertuduhan tersebut dan kemudian menjatuhkan hukuman ke atas Perayu dengan hukuman **RM800.00 atau penjara selama 30 hari jika gagal bayar denda dan penjara selama enam puluh (60) hari.**

[4] Perayu tidak berpuashati dengan hukuman penjara, dan telah merayu ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Y.A Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) dalam keputusannya telah menolak rayuan Perayu dengan mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam bertarikh 23 April 2015.

[5] Perayu tidak berpuashati terhadap keputusan mengekalkan hukuman penjara tersebut dan Perayu telah memfailkan permohonan Kebenaran Merayu melalui kes no. 10000-102-0011-2016. Perayu telah mendapatkan kebenaran merayu ini pada 26/1/2017.

[6] Mahkamah Rayuan Syariah semasa meluluskan permohonan kebenaran merayu pada 26/1/2017 telah menetapkan satu (1) isu sahaja berkaitan undang-undang berkepentingan awam yang boleh dibangkitkan dalam rayuan ini sebagaimana yang dinyatakan diperenggan 19 Alasan Penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah iaitu *“Oleh yang demikian, hanya satu isu sahaja yang boleh dibawa oleh Pemohon di dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan Syariah iaitu sama ada hukuman pemenjaraan wajar dikenakan kepada pesalah yang melakukan kesalahan kali pertama dalam kes matrimoni.”*

[7] Oleh yang demikian, kami hanya perlu menfokuskan isu rayuan dalam kes ini dan terhad kepada isu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Rayuan semasa membenarkan rayuan ini dibuat.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Perayu telah mengemukakan satu (1) Petisyen Rayuan seperti yang dinyatakan di muka surat 239 Rekod Rayuan. Responden iaitu Ketua Pendakwa Syarie juga telah mengemukakan penghujahan balas kepada Mahkamah ini terhadap petisyen rayuan yang dikemukakan oleh Perayu.

[9] Setelah kami meneliti rekod rayuan, kami ingin membuat teguran terhadap pihak Perayu kerana sepatutnya bagi kes ini Perayu menunjukkan kepada mahkamah, isu yang dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah ketika memberi kebenaran untuk merayu. Walau bagaimanapun, kami tidak dibekalkan dalam rekod rayuan alasan penghakiman Mahkamah Rayuan mengenai isu yang berkepentingan awam sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam (Negeri Selangor) 2003.

[10] Semasa pendengaran kes pada 9/1/2018, Mahkamah telah mengarahkan pihak Perayu menunjukkan isu kepentingan awam, namun pihak Perayu tidak dapat berbuat demikian dan kami telah mengarahkan memasukkan dokumen tambahan berkaitan dengan isu tersebut.

[11] Namun amat dikesali pihak Perayu telah memberi perintah bagi kes kebenaran merayu yang bertarikh 26/1/2017. Perintah tersebut telah pun terkandung di dalam rekod rayuan muka surat 258-259. Untuk memberi keadilan kepada pihak Perayu, dengan bidangkuasa yang telah diberikan kepada

Mahkamah Rayuan Syariah di bawah seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam (Negeri Selangor) 2003, maka kami telah menyemak dan meneliti fail permohonan kebenaran merayu bagi mendapatkan isu yang berkepentingan awam yang telah dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

[12] Oleh yang demikian, kami membuat kesimpulan hanya terdapat satu (1) isu sahaja berkenaan undang-undang berkepentingan awam yang disentuh oleh Mahkamah Tinggi Syariah semasa menjalankan kuasa rayuan dari Mahkamah Rendah Syariah iaitu:-

Isu: Sama ada hukuman pemenjaraan wajar dikenakan kepada pesalah yang melakukan kesalahan kali pertama dalam kes matrimoni.

[13] Suatu prinsip kukuh (establish) dalam perundangan kita bahawa mahkamah yang menjalankan kuasa rayuan keberatan untuk campur tangan atau mengganggu sesuatu hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan ianya jelas silap dalam ertikata ianya taksah atau tak bersesuaian dengan fakta yang terbukti atau keadaan kes.

[14] Dalam kes ini, semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, Perayu telah mempetisyenkan di dalam petisyen rayuan 1 (m.s 209 Rekod Rayuan) seperti berikut:-

1.1 Tuan Hakim telah gagal membuat pertimbangan yang sewajarnya terhadap rekod kesalahan Perayu di mana pengakuan salah Perayu adalah bagi kesalahan Pertama yang seharusnya Tuan Hakim memberi peluang kepada Perayu dengan tidak menjatuhkan hukuman penjara yang berat kepada Perayu.

[15] Perayu dalam hujah telah menyatakan bahawa hukuman memenjarakan seseorang yang berpoligami tanpa kebenaran adalah tidak wajar kerana ia melibatkan kesalahan prosedur perkahwinan sahaja. Kewajaran hukuman penjara selama 60 hari tersebut gagal dijelaskan secara wajar dan munasabah oleh Yang Arif Hakim Bicara.

[16] Petisyen ini juga telah dihujahkan oleh Perayu di Mahkamah Tinggi Syariah (m.s 24 Rekod Rayuan). Hujahan Perayu adalah:-

“Di dalam kes ini, Perayu tidak sepatutnya dijatuhkan hukuman yang berat seperti penjara 60 hari yang telah diberikan oleh Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam. Kami menghujahkan tidak terdapat faktor pemberatan bagi Mahkamah memberikan hukuman yang keras seperti itu. Rayuan pemberatan hukuman yang dipohon oleh Pendakwa Syarie hanyalah disebabkan Perayu gagal merayu dan perayu memberikan jawapan “tiada apa-apa”.

[17] Manakala di m.s 12 hujahan Perayu berbunyi:

“Perayu pada masa ini adalah seorang ketua keluarga bagi dua (2) buah keluarga dan tentunya hukuman pemenjaraan ini tidak adil bagi beliau kerana ia boleh menjejaskan perlaksanaan tanggungjawab oleh beliau untuk menyara dan memberi perlindungan kepada kedua buah keluarganya. Hukuman yang dikenakan ke atas Perayu tentunya diharap tidak menyebabkan kesengsaraan berpanjangan sekurang-kurangnya kepada dua buah keluarga dan membawa kepada kemudaratan terhadap komuniti dalam masyarakat”.

[18] Seksyen 129 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana yang dirujuk, menghendaki sebelum sesuatu hukuman ditetapkan bagi kes-kes yang boleh dipenjara, Mahkamah hendaklah mengambil kira watak, latar belakang, umur, kesihatan, mental atau hakikat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pesalah.

[19] Kami telah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) Syariah menyatakan bahawa (perenggan 19 m.s 212 Rekod Rayuan):-

“Selain itu, adakah penerimaan kedua-dua faktor (pengakuan salah dan kesalahan kali pertama) ini sebagai peringan hukuman bersifat mandatori atau sekadar prinsip umum sahaja? Mahkamah berpandangan kedua-dua faktor bukanlah suatu faktor yang secara mandatori atau automatik dikira sebagai peringan hukuman bahkan perlu pertimbangan bersama-sama faktor yang lain juga.”

[20] Jawapan kami kepada isu ini ialah selari dengan dapatan Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) Syariah di atas bahawa kesalahan kali pertama bukanlah bersifat mandatori menghalang Mahkamah Syariah menjatuhkan hukuman penjara kepada Tertuduh. Persoalan sama ada hukuman pemenjaraan wajar dikenakan kepada pesalah yang melakukan kesalahan pertama, bergantung pada pelbagai faktor peringanan dan pemberatan yang ada. Selalunya antara faktor yang boleh yang menentukan sesuatu hukuman adalah sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen 129(1) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Selangor) 2003. Selain itu, telah menjadi amalan penghakiman, faktor-faktor peringanan lain seperti **pengakuan bersalah** dan pernyataan taubat, pesalah bawah umur, **rekod peribadi yang baik**, kesan hukuman terhadap kesihatan pesalah dan **kesalahan pertama kali**

dilakukannya turut diambil perhatian. Manakala faktor-faktor yang boleh memberatkan hukuman pula ialah rekod buruk pesalah, taraf perkahwinan, taraf pesalah di dalam masyarakat dan kedudukannya yang tinggi, kekerapan kesalahan dilakukan dan penggunaan kekerasan dan keganasan semasa melakukan kesalahan. Prinsip penghakiman ini telahpun diaplikasikan di dalam kes-kes matrimonial sebelum ini antaranya ialah *kes rayuan Mokhtar Bin Raden lwn. Pendakwa Syarie Selangor JH Jld.32 Bhg.1 Hal. 69* dan *Mhd Idris Bin Masior lwn Ketua Pendakwa Syarie* dalam Kes Rayuan Jenayah No: 10000-166-0012-2015.

[21] Kembali kepada kes ini yang dibicarakan di Mahkamah Rendah, kami dapati Hakim Bicara telah mengulas prinsip-prinsip penghakiman sebagaimana panduan di atas, namun pada dapatan kami, Hakim Bicara gagal memberi pertimbangan wajar terhadap hal peringanan kesalahan yang dilakukan Perayu sebagaimana ulasannya di muka surat 194-202 Rekod Rayuan.

[22] Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) Syariah pula menyatakan dalam alasan penghakimannya di perenggan 8, muka surat 313 Rekod Rayuan iaitu:-

“Hakim Bicara telah menjelaskan bahawa tindakannya tidak mempertimbangkan faktor peringan hukuman adalah disebabkan ianya tidak dibangkitkan oleh mana-mana pihak semasa prosiding dijalankan dihadapanya, Hakim Bicara juga sedar bahawa budi bicara di dalam membuat anggapan dan dapatan adalah berada ditangannya namun enggan berbuat demikian kerana tidak dibangkitkan dan bertujuan menggelakan prejudis kepada hak pendakwaan”.

[23] Di muka surat 313 Rekod Rayuan tersebut, Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) Syariah juga menyatakan:-

“Mahkamah berpendapat Hakim Bicara telah menggunakan kuasa budi bicara dengan sewajarnya sebagaimana yang dijelaskan. Ini dikuatkan lagi Perayu tidak membuat sebarang rayuan berhubung kedua-dua faktor (pengakuan salah dan kesalahan kali pertama) ini semasa diberi peluang oleh Mahkamah Bicara.”

[24] Apabila kami meneliti alasan penghakiman Hakim Mahkamah Rendah Syariah pula, Hakim Bicara menyatakan:-

“Sebelum Mahkamah menjatuhkan hukuman, Mahkamah telah memberikan ruang dan peluang kepada tertuduh untuk merayu apa-apa rayuan peringan hukuman. Namun, Tertuduh menjawab “tiada apa-apa. Mengejutkan, Tertuduh tidak memohon apa-apa rayuan peringan hukuman”.

[25] Kami dapati isu rayuan mengurangkan hukuman telah dibangkitkan oleh Hakim Bicara di dalam alasan penghakimannya. Namun Hakim Bicara berpendapat bahawa Perayu tidak menzahirkan tanda-tanda penyesalan, jauh sekali menyatakan penyesalan. Perayu tidak menggunakan peluang yang ada bagi menyakinkan Mahkamah untuk meringankan hukuman ke atas Perayu (merujuk kepada perenggan 27 dan 28, muka surat 198 Rekod Rayuan).

[26] Berdasarkan alasan penghakiman Hakim Bicara di perenggan 36-39, muka surat 202 Rekod Rayuan, Hakim Bicara telah membuat kesimpulan *“...hukuman denda bersama pemenjaraan sebagai hukuman yang sesuai terhadap tertuduh...”* dan *“...denda semata, jika dihukumkan, nescaya keadilan dan tujuan hukuman tidak dapat dicapai. Denda per se akan hanya memberi*

peluang kepada pesalah untuk membeli keadilan...serta "...berharap agar hukuman yang dijatuhkan akan memberi kesedaran kepada Tertuduh..."

[27] Di dalam meneliti pilihan hukuman ini, adalah menjadi tanggungjawab mahkamah dalam memastikan setiap hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang pesalah atau tertuduh adalah hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan dan memastikan hukuman yang boleh dijadikan sebagai panduan kepada tertuduh dan masyarakat Islam awam lain dan mendidik tertuduh khususnya serta masyarakat amnya supaya patuh kepada perintah Allah, rasul dan pemimpin.

[28] Walaupun pada dasarnya, Mahkamah berpendapat bahawa pilihan hukuman adalah tidak mengikat mana-mana Mahkamah dalam menjatuhkan hukuman ke atas seseorang pesalah. Namun, Mahkamah percaya bahawa setiap para hakim itu hendaklah menilai dengan penuh teliti sehingga tahap yang mewajarkan sesuatu hukuman itu ditentukan atas sesuatu kesalahan.

[29] Merujuk kepada hukuman pemenjaraan yang dihukumkan ke atas Perayu di dalam kes, Mahkamah berpendapat bahawa seharusnya Hakim Bicara menitikberatkan tentang penelitian dan penilaian dalam menentukan hukuman tersebut, sama ada ianya benar-benar wajar dan munasabah untuk dihukumkan ke atas kes seumpama ini. Mahkamah juga berpendapat seharusnya Hakim Bicara mengulas dan menerangkan secara terperinci alasan-alasan dan sandaran yang muktabar dalam penghakiman tersebut.

[30] Kami juga tidak menemui di dalam Alasan Penghakiman Hakim Bicara MRS dan Yang Arif Hakim MTS berkenaan *signifikannya* hukuman 60 hari pemenjaraan berdasarkan teori pemulihan dan pencegahan ke atas Perayu. Kami dapati hukuman pemenjaraan tersebut hanyalah semata-mata suatu pembalasan

akibat kegagalan Perayu membuat rayuan terhadap hukuman pemenjaraan ketika proses mitigasi di hadapan Hakim Bicara.

[31] Kami juga dapati Hakim Bicara tidak mempertimbangkan latar belakang Perayu, jenis kesalahan yang dipertuduhkan, pengakuan bersalah Perayu dan hakikat kesalahan kali pertama yang dilakukan Perayu dengan sewajarnya. Kami dapati hukuman penjara yang dikenakan ke atas Perayu atas kesalahan matrimonial kali pertama adalah suatu hukuman yang berat.

[32] Kami berpendapat hukuman Perayu pemenjaraan selama 60 hari adalah hukuman yang berlebihan. Kaedah deteren/pencegahan yang munasabah ke atas Perayu ialah denda tanpa hukuman pemenjaraan. Kesan hukuman penjara ke atas Perayu lebih memberi kesan negatif dari aspek peribadi serta melibatkan orang-orang di bawah tanggungan Perayu. Kami berpendapat Perayu masih boleh diberi peluang untuk memperbaiki kesilapannya berdasarkan ini adalah kesalahannya kali pertama. Ini bersesuaian dengan keadah Fiqh al Mumkin ‘*Ala Daw’ Qa’idat al-Maysur La Yasqut bil Ma’sur* (الميسور لا يسقط بالمعسور) dalam kitab karangan Dr Naji Ibrahim Al-Suwayd yang menyebut:-

فى تغيير المنكر حتى لا يضيع هذا الأصل بعدم الصبر عليه كأن يتولد من أزالته ما هو أكبر منه

“Dalam kita mengubah sesuatu kemungkaran, kita tidak boleh membiarkan tujuan asal hilang sehingga menyebabkan timbul perkara baru yang lebih besar.”

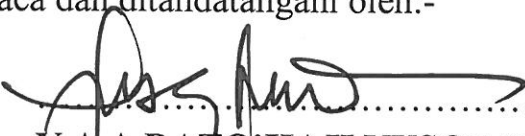
[33] Dalam hal ini, kami dapati Hakim Mahkamah Tinggi telah terkhilaf apabila mengekalkan hukuman pemenjaraan 60 hari bagi kes ini walaupun hukuman pemenjaraan tersebut bertujuan untuk pemulihan dan pencegahan kepada Perayu. Kami berpandangan hukuman denda maksimum sahaja telah mencukupi dalam kes ini dan hukuman pemenjaraan wajar diketepikan

KEPUTUSAN

Setelah meneliti Rekod-Rekod Rayuan, hujah dan alasan Perayu, hujah Responden serta dokumen-dokumen yang dikemukakan sebagai ekshibit, otoriti undang-undang dan laporan kes, Maka dengan ini Kami sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:-

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Y.A. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Jenayah No: 10500-166-0005-2016 diubah :-
 - i. Hukuman denda sebanyak RM1000 atau 6 bulan penjara jika gagal membayar denda.
 - ii. Hukuman Penjara 60 hari ke atas Perayu diketepikan.
3. Bon jaminan dikembalikan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. **Y.A.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **Y.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HJ. MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **Y.A TUAN HAJI AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

